

1516475-83.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... que o local é conhecido pelo forte tráfico de entorpecente, é uma residência abandonada onde o tráfico ocorre dentro. Fizeram uma breve campana, viram que entrava e saía pessoas, desembarcaram e entraram correndo em um buraco no muro e subiram em um mezanino e tinha um rapaz sentado no chão com uma quantia em dinheiro, quatro aparelhos celulares e pedras de crack. O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516475-83.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516475-83.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO FERREIRA SALGADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

ADRIANO FERREIRA SALGADO, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06, ambos c.c. o art. 69 do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 21 de julho de 2022, por volta das 15h15, na Rua dos Estudantes, n.º 350, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia ilícita, drogas consistentes em 03 gramas de Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, acondicionada em 14 (quatorze) porções de "crack", devidamente apreendidas e periciadas, sendo que o acusado as guardava e as tinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$ 191,00 (cento e noventa e um reais) e 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular. Consta na denúncia que, nas mesmas circunstâncias dos fatos, o réu associou-se com terceiras pessoas não identificadas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que possui relação estável com a associação, com trabalho fixo na venda, sendo remunerado pelo valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) por dia trabalhado, recusando-se a falar quem o contratou. No dia dos fatos, os policiais civis, que realizavam operação de combate ao tráfico no local dos fatos, avistaram um indivíduo sentado em um colchão em uma casa abandonada, em poder de 14 pedras de crack, 04 aparelhos

celulares e a quantia de R\$ 191,00.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls. 109/111). Na oportunidade, foi designado audiência de instrução, debates e julgamento.

O acusado foi citado às fls. 142 e apresentou resposta a acusação às fls. 146.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e os réus interrogados ao final.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu.

A Defesa requereu a absolvição diante da falta de provas, subsidiariamente a aplicação da pena mínima.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 34/36 e fls. 37/39), laudo de constatação (fls. 19/21) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 120/122).

O mesmo pode ser dito em relação à autoria. As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: encontrar o réu em local conhecido como ponto de venda de drogas, em atitude suspeita, não autoriza qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para o delito de porte de substância ou absolvição.

Perante a autoridade policial o réu se reservou ao seu direito de permanecer calado. (fls. 09)

Em juízo o réu Adriano disse que é usuário de crack desde 1984, já viveu em situação de rua. Na data dos fatos, estava na casa, mas levava consigo uma pedra e meia de crack. Tinha R\$ 211,00 no bolso e cada pedra é 10 reais, fez a compra de duas pedras, fez uso de meia pedra e então os policiais chegaram. Estava junto com os usuários não na parte de cima. Estava bem vestido, não é porque usa droga que anda sujo e fedido. Os policiais falaram que se não indicasse quem era o traficante iriam imputa-lo o crime. O traficante é um rapaz chamado R7. Comprou a droga no fundo da casa, não no segundo andar, não prenderam o traficante. Nenhum dos outros usuários foram detidos. Tinha feito um trabalho com gesso na Conselheiro Furtado nº 1650, recebeu R\$ 211,00 e ainda faltava R\$ 400,00. Recebeu o dinheiro no dia que foi preso. Já tinha sido abordado pelos policiais e eles queriam que ele fosse informante.

A negativa da ré além de pouco crível restou isolada das demais provas acostadas aos autos.

Em juízo, a testemunha Eliedes Lombardi, policial civil disse que na data dos fatos foram ao local que é conhecido pelo tráfico de entorpecente onde já fizeram mais de 20 flagrantes denunciados por populares. Fizeram campana em uma casa abandonada e viram usuários entrando e saindo, então entraram na casa e subiram até o andar de cima, um mezanino, o réu estava sentado no colchão contando dinheiro em notas de pequeno valor e ao lado dele 4 aparelhos celulares e pedras de crack. O réu disse que estava no tráfico há 2 semanas e que ganharia R\$ 80,00 por dia. Não conhecia o réu. Tinham usuários no andar de baixo, e como sabiam que o traficante ficava no andar de cima, e se abordarem os usuários o traficante dispensa a droga. Fizeram 5 minutos de campana, cerca de 5 pessoas entraram. A viatura apesar de descaracterizada, eles já conhecem então não podiam demorar muito. Os celulares estavam desligados.

Já o policial Fernando Scarpante Martins, afirmou na audiência que o local é conhecido pelo forte tráfico de entorpecente, é uma residência abandonada onde o tráfico ocorre dentro. Fizeram uma breve campana, viram que entrava e saía pessoas, desembarcaram e entraram correndo em um buraco no muro e subiram em um mezanino e tinha um rapaz sentado no chão com uma quantia em dinheiro, quatro aparelhos celulares e pedras de crack. O réu disse que estava desempregado e ganharia R\$ 80,00 e que estava trabalhando há duas semanas. A campana durou cerca de 5 minutos e cerca de 4 ou 5 pessoas saíram. Nenhuma dessas pessoas foi abordada pois o foco é o traficante. Na parte de baixo tinham alguns usuários que se evadiram, em cima só tinha o réu, é um mezanino de madeira. Os celulares estavam desligados, eram aparelhos antigos, mais moderno tinha apenas um, não olharam as mensagens. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais gozam da mesma

valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos, bem como acrescentando que não conheciam o acusado até a data dos fatos. O relato foram firmes, coerentes e detalhados.

A palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado. Assim, não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicar o réu, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Os policiais disseram que não conheciam o réu e inclusive afirmaram que ele confessou dizendo que apenas estaria no local há duas semanas. Ora, se eles efetivamente quisessem prejudicar o acusado teriam lhe imputado fatos mais graves, o que não fizeram.

Ademais, não há motivo para crer que os policiais, diante de diversas pessoas, tenha elegido o réu para imputar crime tão grave.

Ainda, o réu afirma que o dinheiro que tinha recebido foi em um serviço feito na Av. Conselheiro Furtado nº 1650, e em consulta ao Google maps não consta local com este número e o mais próximo seria uma grande farmácia e não um pequeno comércio como afirmado pelo réu, caindo por terra a versão quanto a origem dos valores.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à guarda ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes da quantidade, circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Pelos mesmos motivos, incabível a desclassificação para o delito de uso de entorpecente.

Também não é possível reconhecer o delito de associação para o tráfico, já que o fato do agente afirmar que trabalhava na traficância recebendo o valor de R\$ 80,00 por dia, há duas semanas, não gera o delito de associação, dado que com ele nada mais foi encontrado que indicassem que ele tinha conduta organizada e hierarquizada para o cometimento do crime.

O objetivo da lei foi punir mais fortemente aqueles que se unem para a prática do delito de forma organizada e estável em que haja divisão de tarefas.

Nesse sentido:

Para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas faz-se mister a comprovação da existência de animus associativo entre os agentes. O simples fato de serem companheiros e praticarem o comércio ilícito dentro de suas casas não é suficiente para a caracterização do crime." (TJAM. Relatora Carla Maria Santos dos Reis. Data de julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara Criminal)

Ora, ainda que possível a hipótese de associação, com a finalidade de cometer o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A propósito, dispõe o referido artigo, verbis: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes

previstos nos artigos 33, caput e parágrafo primeiro, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, entretanto, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer. De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

No caso dos autos, não existem elementos sólidos a embasar o édito condenatório pelo grave delito, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, deve restar indubitavelmente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade.

Sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados:

"TÓXICOS - TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO - CONCURSO DE AGENTES - INOCORRÊNCIA - PROVA INSUFICIENTE - DEPOIMENTOS SUSPEITOS DE POLICIAIS - RECEPÇÃO DOLOSA - AGENTE QUE ARREBATA, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM MÓVEL DE OUTREM COMO RESSARCIMENTO PELA VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - DELITO DESCARACTERIZADO. Não há falar no crime autônomo de associação (Art. 14 da Lei nº 6.368/76) se os elementos de convicção coligidos nos autos não demonstra com a indispensável segurança a existência, entre os agentes, de um 'animus' associativo, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma 'societas sceleris' à prática do crime visado. (...)." (TJMG, 1ª C.Crim., APCR nº 1.0024.04.383774-9/001, Rel. Des. Gudesteu Biber, v.u. julg. 18.10.2005; pub. no DOMG de 26.10.2005).

Diante desse quadro, a parcial procedência da ação é de rigor.

Passo, pois, a dosagem das penas.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que a culpabilidade é ordinária, não podendo ser tomada como negativa. No entanto, o acusado registra maus antecedentes (fls. 87/92), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo ao acusado. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. Atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal, aumento a pena-base em 1/8, resultando em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência. Assim, aumento a pena em 1/6 passando ao patamar de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 656 dias-multa.

Não existem causas de aumento a serem consideradas e não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que o réu é reincidente, conforme certidão acostada aos autos. Assim, o acusado não faz jus à redução, pois não estão presentes os requisitos legais para aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Noto, por oportuno, que não há inconstitucionalidade na aplicação da reincidência como motivo a afastar a concessão da causa de diminuição, uma vez que ela expressa uma maior censura ao agente, a quem, pela condenação anterior, tinha consciência mais ampla da ilicitude de sua ação, das consequências penais e, por isto mesmo, sendo-lhe exigível especial conduta diversa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas. Por fim, considerando a quantidade da pena, e a gravidade do delito que inclusive é previsto como hediondo, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como deixo de conceder "Sursis".

Em face da quantidade da pena e reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado ADRIANO FERREIRA SALGADO, à pena 06 ano, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 655 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Tendo o réu respondido preso e considerando a quantidade de pena aplicada e o regime de cumprimento de pena não faculto eventual apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, tendo sido defendido pela defensoria pública, isento o réu das custas.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

P.I.C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA